刑法07 筆記：違法性基礎與容許構成要件錯誤

> 來源：刑法07 課程字幕 01:44:00 ~ 02:42:17

🕮 法條原文速查

> **§16**（法律之不知）
> 除有正當理由而**無法避免**者外，不得因**不知法律**而免除刑事責任。但按其情節，得減輕其刑。

> **§23**（正當防衛）
> 對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。

> **§24**（緊急避難）
> 因避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為，不罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其刑。

> **§55**（想像競合）
> 一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。

> **民法 §151**（自助行為）
> 為保護自己權利，對於他人之自由或財產施以拘束、押收或毀損者，不負損害賠償之責。但以不及受法院或其他有關機關援助，並非於其時為之，則請求權不得實行或其實行顯有困難者為限。

📋 實務見解速查

> **74 臺上 4225 判例**：關於「實質違法性」之論述。實際內容論述的是可罰的違法性概念（行為輕微 + 法益侵害輕微），但用語為「欠缺實質違法性」而非「欠缺可罰的違法性」→ 掛羊頭賣狗肉。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「欠缺可罰違法性需具備哪些條件？」	**兩個都要輕**：①行為本身輕微 ②法益侵害結果輕微
「拿刀威脅取得一張白紙，可否主張欠缺可罰違法性？」	**不可以**：行為（加重強盜）不輕微，不符合要件
「可罰違法性與實質違法性有何不同？」	實質違法性＝行為本身不違反社會通念；可罰違法性＝行為不OK但法益侵害量太少
「違法與不法有何區別？」（德國學說立場）	**違法**＝有跟沒有（二分法）；**不法**＝有程度高低（民事→行政→刑事）
「超法規阻卻違法事由是否違反罪刑法定？」	**不違反**：多一種阻卻違法事由 = 多一條無罪空間，對行為人有利
「容許構成要件錯誤的通說效果？」	多數說：**阻卻故意，視情況改論過失犯**；僅嚴格罪責理論用§16處理
「誤想防衛是否為不法意識的欠缺？」	**否**（限制法律效果罪責理論/二階論）：行為人是**對事實誤認**，非對法規範誤解，不符§16
「對應原理在違法性是否適用？」	**不適用**（蔡聖偉採累加理論）：阻卻違法事由無需主客觀對應

一、違法性基礎概念

推定違法

- 構成要件該當 → **推定違法**
- 理由：經驗上，符合刑法分則構成要件的行為，絕大多數為不正當行為（100件中僅1~2件正當）

阻卻違法事由的來源

```
阻卻違法事由
│
├── 法規阻卻違法事由（法律明文規定）
│     例：§23 正當防衛、§24 緊急避難、§21 依法令行為
│
└── 超法規阻卻違法事由（法律未規定，事理上承認）
      → 不違反罪刑法定（對行為人有利）
```

阻卻違法事由的三格審查

```
┌──────────┬──────────┬──────────┐
│ 前提事實  │ 手段適當  │ 主觀認知  │
│（客觀）   │（客觀）   │（主觀）   │
├──────────┼──────────┼──────────┤
│ ✓ 有      │ ✓ 適當    │ ✓ 有認知  │ → 阻卻違法
│ 任一 ✗    │           │           │ → 不阻卻違法
└──────────┴──────────┴──────────┘
```

二、可罰的違法性

爭議核心：違法性有無程度高低？

（一）日本學說：肯定（欠缺可罰的違法性）

兩個條件都要輕微：

1. **行為本身**輕微（與社會相當的程度）
2. **法益侵害結果**輕微

→ 兩者皆輕 → 欠缺可罰的違法性 → **不成立犯罪**

案例	行為輕微？	法益侵害輕微？	可罰違法性？
偷吃一顆荔枝	✓	✓	欠缺 → 無罪
偷用一點水洗手	✓	✓	欠缺 → 無罪
亮刀威脅取一張白紙	✗（加重強盜）	✓	**不可主張**

> 東吳轉學考考題：甲未經同意從機車行水龍頭取水，用一小撮洗衣粉洗手 → 欠缺可罰的違法性

（二）德國學說 / 林山田立場：否定

- **違法**：有跟沒有的問題（二分法），不存在「有一點違法」
- **不法**：才有程度高低（民事不法 < 行政不法 < 刑事不法）
- 可罰違法性理論**混淆了違法與不法**的概念
- 法益侵害量低的行為 → 犯罪仍成立，但量刑/程序處理（罰金、緩起訴）

實務問題

- 74 臺上 4225 判例使用「實質違法性」用語
- 實際內容 = 可罰的違法性
- 學者批評：**掛羊頭賣狗肉**（實質違法性 ≠ 可罰違法性）

三、阻卻違法事由的主客觀合致

客觀欠缺 + 主觀具備 → 容許構成要件錯誤（誤想防衛）

- 例：以為路人要猥褻我，踹了一腳 → 實際路人只是提醒揹包拉鏈
- 客觀：無現在不法侵害 ✗ / 主觀：以為有侵害 ✓

客觀具備 + 主觀欠缺 → 偶然避難（反面容許構成要件錯誤）

- 例：基於報復砸仇人窗戶 → 實際仇人家瓦斯漏氣，砸窗反而救命
- 客觀：生命危險確實存在 ✓ / 主觀：對危險一無所知 ✗

四、對應原理在違法性的適用

問題

客觀實現 A 阻卻違法事由，主觀出於 B 阻卻違法事由，可否阻卻違法？

案例（蔡聖偉文章 / 北大刑法組考題）

- A 從國外帶回新型手機，在圖書館被偷
- 數天後見到 B 拿同樣手機，誤以為是自己的手機
- A 上前攔住 B（客觀：§23 正當防衛的前提可能存在；主觀：以為在做民法§151 自助行為）

兩說

學說	立場	結論
連接理論	需要對應	A客觀 + B主觀 → 不可阻卻違法
累加理論 ☑（蔡聖偉）	不需要對應	A客觀 + B主觀 → 可以阻卻違法

理由（黑咖啡哲學例子）

- 在無阻卻違法事由時，行為人只需認知「行為不正當」即可
- 不可能要求行為人認知到**什麼樣的「沒有」**→ 如同黑咖啡不加鮮奶油 vs 不加熱牛奶→意思相同
- 違法性判斷的本質 = 反面判斷 → 不適用對應原理

五、容許構成要件錯誤五說

總覽

學說	搭配體系	核心主張	效果
① **故意理論**	古典犯罪體系	欠缺不法意識 → 阻卻故意	阻卻故意
② **嚴格罪責理論**	現代三階論	欠缺不法意識 → 依§16處理	可避免→減輕；不可避免→無罪
③ **限制罪責理論**	現代三階論（德國）	類推適用構成要件錯誤（德§16 I）	阻卻故意
④ **限制法律效果罪責理論** ☑	現代三階論（我國通說）	欠缺罪責故意（良知非難）	阻卻故意
⑤ **二階論/負面構成要件理論**	二階犯罪體系	不法故意未完整認識	阻卻故意

（一）故意理論（古典犯罪體系）

背景：100年前的三階論中，故意在**罪責**層判斷，且故意須認識**不法意識**

古典三階論：	現代三階論：
構成要件（全客觀）	構成要件（客觀+主觀＝故意）
違法性（全客觀）	違法性（客觀+主觀）
罪責（故意+不法意識）	罪責（責任能力+不法意識+期待可能）

- 誤想防衛 → 行為人以為行為合法 → 欠缺不法意識 → 阻卻故意 → 無故意犯罪

（二）嚴格罪責理論

- 同樣認為是**不法意識欠缺**
- 但在現代三階論下，不法意識是純粹的罪責要素（§16），不再能阻卻故意
- 效果：依§16處理 → 可避免：減輕其刑 / 不可避免：免除刑事責任

> ⚠ 嚴格罪責理論是五說中**唯一不阻卻故意**的學說

（三）限制罪責理論（德國流行，我國水土不服）

- 容許構成要件錯誤 = 對**事實**的誤認（非法規範誤解）
- 與構成要件錯誤很像 → **類推適用**構成要件錯誤 → 阻卻故意
- **問題**：類推適用的對象是**德國刑法§16 I**，我國無對應法條
- 我國講構成要件錯誤阻卻故意時，並未援引特定法條 → **類推適用什麼？** → 水土不服

（四）限制法律效果的罪責理論（我國通說）☑

提出**罪責故意**概念：

罪責故意 = 良知非難
= 行為人有沒有想跟法律敵對的意思

一般案例：無故揍人 → 構成要件故意 ✓ + 罪責故意 ✓
誤想防衛：以為在防衛 → 構成要件故意 ✓ + 罪責故意 ✗（良知不值得被譴責）
→ 欠缺罪責故意 → 阻卻故意 → 視情況改論過失犯

> 批評：罪責故意是為容許構成要件錯誤**量身打造**的概念，無其他適用場景

（五）二階論 / 負面構成要件理論

二階論基本架構：構成要件 + 違法性 = 合併為同一階「不法」

二階論的故意須認識：
① 正面不法事實（行為、結果、因果、歸責）
② 無阻卻違法事由（負面不法事實）

誤想防衛：
客觀正面不法 ✓ / 客觀負面不法 ✓（確實無正當防衛情境）
主觀正面認識 ✓ / 主觀負面認識 ✗（以為在防衛）
→ 主觀不完整 → 阻卻故意

- **優勢**：不需要額外發明學說，體系內即可得出正確結論
- 代表學者：黃榮堅老師

解題記憶口訣

- **多數說**：阻卻故意，視情況改論過失犯
- **唯一例外**：嚴格罪責理論 → 用§16處理（可避免減輕/不可避免免除）

誤想防衛過當

- 通說：可類推適用/適用防衛過當（§23但書）、避難過當（§24但書）之減免規定

六、§16 之正確適用

不法意識欠缺 vs 事實誤認

	不法意識欠缺（§16）	容許構成要件錯誤
誤認對象	**法規範**	**事實**
例子	外國人不知台灣禁止吸毒	以為路人要攻擊我
行為人認知	不知行為違法	知道行為是什麼，但誤認情境
適用法條	§16	非§16（對事實誤認，非不知法律）

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§16	法律之不知（禁止錯誤）	嚴格罪責理論的處理依據
§23	正當防衛	誤想防衛的核心條文
§24	緊急避難	偶然避難/誤想避難
民法§151	自助行為	對應原理案例

關鍵學說速查表

學者/文獻	立場/理論
蔡聖偉	累加理論（對應原理不適用於違法性）、北大法研所考題
許恆達（謝安）	典型構成要件行為標準說（臺大法研所出題）
黃榮堅	二階論/負面構成要件理論
林山田	否定可罰違法性理論（流德學者）